

<제2편 소송의 주체.제4장 당사자.제2절 당사자의 자격>

I. 당사자능력

1. 서설

(1) 의의

- 당사자능력이란 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력을 의미한다. 이는 민법상의 권리능력에 대응하는 개념으로, 원고나 피고가 되어 재판을 받을 수 있는 법률상의 자격이다.

(2) 구별개념

- 당사자능력이 소송의 주체가 될 수 있는 추상적 자격이라면, 당사자적격은 구체적인 소송물에 대하여 본안판결을 받기에 적합한 자격을 의미한다. 또한 소송능력은 스스로 유효한 소송행위를 할 수 있는 능력을 의미하므로 당사자능력과는 구별된다.

2. 실질적 당사자능력

- 실질적 당사자능력은 민법상 권리능력자에게 인정된다. 따라서 자연인은 생존하는 동안 누구나 당사자능력을 가지며, 태아는 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구 등에서 권리능력이 인정되는 범위 내에서 예외적으로 당사자능력이 인정된다. 법인 역시 설립등기를 마침으로써 권리능력을 취득함과 동시에 당사자능력을 가진다. 외국인이나 외국법인도 상호주의 원칙이나 관련 법령에 따라 당사자능력이 인정된다.

3. 형식적 당사자능력

(1) 비법인사단의 소송수행방안

- 민사소송법 제52조는 법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단이나 재단의 이름으로 당사자가 될 수 있다고 규정한다. 이는 실체법상 권리능력이 없더라도 사회적 실체로서 활동하는 단체의 분쟁을 효율적으로 해결하기 위한 소송법적 정책에 해당한다. 비법인사단이 당사자가 되기 위해서는 단체로서의 조직을 갖추고 의사결정기관과 집행기관이 존재하며, 고유한 목적을 가지고 구성원의 변동과 관계없이 단체 자체가 존속해야 한다.

(2) 조합의 소송수행방안

- 민법상 조합은 원칙적으로 당사자능력이 없다. 조합의 사무에 관한 소송은 조합원 전원이 공동으로 제기하거나(고유필수적 공동소송), 조합원 중 1인 또는 제3자를 선정당사자로 내세워 수행해야 한다. 다만, 판례는 조합의 실질을 갖추었더라도 그 명칭과 상관없이 실무적으로 비법인사단의 요건을 갖춘 경우에는 민사소송법 제52조를 유추 적용하여 당사자능력을 인정하기도 한다. 업무집행조합원이 있는 경우에도 그가 조합 전체를 대리하여 소송을 수행할 수는 있으나, 조합 자체의 이름으로 소를 제기하는 것은 원칙적으로 불가능하다.

4. 당사자능력 조사와 그 흠결의 효과

(1) 소 제기 시 흠결

- 소 제기 당시부터 당사자능력이 없는 자를 상대로 하거나 그 이름으로 소를 제기한 경우, 법원은 직권으로 이를 조사하여야 한다. 보정이 가능한 경우(사자상대소송에서의 표시정정 등)를 제외하고는 소를 각하하여야 한다.

(2) 소송계속 중 흠결

- 소송 도중에 당사자가 사망하거나 법인이 해산된 경우 소송절차는 중단된다. 이때 상속인이나 합병 후의 법인이 소송을 승계하여야 하며, 승계가 이루어지지 않으면 절차를 진행할 수 없다.

(3) 당사자능력에 대하여 다툼이 있는 경우

- 당사자능력의 존부는 소송요건이므로 법원은 증거조사를 통해 이를 확정하여야 한다. 능력의 존재가 불분명한 경우 그 불이익은 소송을 제기한 원고가 부담한다.

(4) 간과판결의 효력

- 당사자능력이 없는 자에 대한 판결은 원칙적으로 무효이다. 사자를 상대로 한 판결은 기판력이 발생하지 않으며, 강제집행의 근거가 될 수 없다. 다만, 비법인사단인데 대표자 자격에 하자가 있는 경우 등은 상소나 재심을 통해 다룰 수 있다.

II. 당사자적격

1. 의의

- 당사자적격이란 특정한 소송물에 대하여 원고로서 소송을 수행하고 본안판결을 받을 수 있는 자격(정당한 원고) 또는 피고로서 소송을 수행당하고 판결을 받을 수 있는 자격(정당한 피고)을 의미한다. 이는 소송수행권이라고도 불리며, 재판의 실효성을 담보하기 위한 소송요건이다.

2. 일반적 당사자적격자

(1) 이행의 소

- 이행의 소에서는 원고가 자기에게 이행청구권이 있다고 주장하는 자가 원고적격을 가지며, 원고로부터 이행의무자로 지명된 자가 피고적격을 가진다. 실제로 청구권이나 의무가 존재하는지는 본안심리 단계에서 판단할 문제이므로, 주장 자체로 적격이 결정된다.

(2) 확인의 소

- 확인의 소에서는 당해 법률관계에 대하여 확인의 이익이 있는 자가 원고적격을 가진다. 즉, 판결을 통해 자신의 법적 지위의 불안을 제거할 필요가 있는 자가 적격자가 된다.

(3) 형성의 소

- 형성의 소는 법률에 규정된 자만이 제기할 수 있다. 예를 들어 주주총회결의취소의 소는 주주·이사·감사만이 제기할 수 있으며, 이들이 정당한 당사자적격자가 된다.

(4) 고유필수적 공동소송

- 여러 사람이 공동으로만 소송을 수행해야 하는 고유필수적 공동소송(공유물 분할의 소)에서는 전원이 함께 참여해야만 당사자적격이 인정된다. 1인이라도 누락되면 당사자적격 흠결로 소가 각하된다.

3. 제3자 소송담당

(1) 의의

- 권리관계의 주체인 당사자가 아닌 제3자가 자신의 이름으로 소송을 수행하고 그 판결의 효력이 권리 주체에게 미치는 경우를 의미한다.

(2) 법정 소송담당

- 법률의 규정에 의해 제3자에게 소송수행권이 부여되는 경우이다. 채권자대위소송을 제기하는 채권자, 파산재단에 관한 소송을 수행하는 파산관재인, 유언집행자 등이 이에 해당한다. 이는 대리인의 지위와 달리 자신의 이름으로 소송을 수행한다는 특징이 있다.

(3) 임의적 소송담당★

- 권리 주체의 의사에 의해 제3자에게 소송수행권을 수여하는 경우이다. 원칙적으로 민사소송법은 변호사대리의 원칙을 잠탈할 우려가 있어 이를 엄격히 제한한다. 다만, 공동의 이해관계를 가진 자들이 선출하는 선정당사자는 법이 명문으로 인정하는 임의적 소송담당이다. 판례는 변호사법 위반의 우려가 없고 소송수행을 맡길 합리적 필요가 있는 특수한 경우(업무집행조합원 등)에 한하여 예외적으로 허용한다.

(4) 제3자 소송담당과 기판력

- 제3자 소송담당에 의해 내려진 판결의 효력(기판력)은 권리관계의 본래 주체인 이익 귀속자에게도 미친다. 다만, 채권자대위소송의 경우 채무자가 대위소송의 제기 사실을 알았을 때에 한하여 기판력이 미친다는 것이 판례의 태도이다.

4. 당사자적격 흠결의 효과

(1) 소제기 흠결

- 원고나 피고에게 당사자적격이 없는 경우 법원은 직권으로 이를 조사하여 소를 각하하여야 한다.

(2) 소송계속 중 흠결

- 소송 도중 권리관계의 양도 등으로 적격이 상실된 경우, 승계인이 소송을 인수하거나 당사자가 소송을 탈퇴하는 절차를 거쳐야 한다.

(3) 당사자적격에 관하여 다툼이 있는 경우

- 본안판결의 전제조건이므로 법원은 증거조사를 통해 적격 유무를 판단한다.

(4) 간과판결의 효력

- 당사자적격이 없는 자에 대한 판결은 원칙적으로 부적법한 판결로서 상소 사유가 된다. 다만, 판결이 확정된 후에는 기판력의 주관적 범위가 문제 될 뿐 판결 자체가 당면무효가 되지는 않는 경우가 많다.

III. 소송능력

1. 서설

(1) 의의

- 소송능력이란 당사자로서 유효하게 소송행위를 하거나 상대방의 소송행위를 수령할 수 있는 능력을 말한다. 이는 민법상의 행위능력에 대응하는 개념이다.

(2) 소송능력자

- 원칙적으로 민법상 성년자인 자는 소송능력을 가진다. 법인이나 비법인사단은 대표자를 통해 소송을 수행하므로 단체 자체가 능력을 가지는 것이 아니라 대표자의 행위로 귀속된다.

2. 소송무능력자[민소법 제55조]

(1) 민법상 제한능력자

- 미성년자, 피성년후견인 등은 원칙적으로 소송능력이 없다. 이들은 법정대리인에 의하여 소송을 수행하여야 한다. 다만, 미성년자가 독립하여 경제 활동을 할 수 있는 경우 등 민법상 예외적으로 행위능력이 인정되는 범위 내에서는 소송능력도 인정된다. 피한정후견인의 경우에는 원칙적으로 소송능력이 있으나, 법원이 정한 범위 내에서는 제한될 수 있다.

(2) 법인 또는 비법인사단·재단

- 이들은 자연인이 아니므로 스스로 소송을 수행할 수 없다. 따라서 법정대리인에 관한 규정이 준용되는 대표자를 통하여서만 소송능력을 행사할 수 있다.

3. 소송법적 효과

(1) 소송행위의 유효요건

- 소송무능력자가 직접 한 소송행위나 그를 상대로 한 소송행위는 원칙적으로 무효이다. 다만, 후에 소송능력을 취득한 당사자나 법정대리인이 이를 추인하면 소급하여 유효하게 된다.

(2) 소송능력흠결의 효과

- 법원은 소송능력의 유무를 직권으로 조사하여야 하며, 흠결이 발견된 경우 기간을 정하여 보정을 명한다. 보정이 불가능하거나 불응할 시 소를 각하한다.

IV. 변론능력

1. 의의

- 변론능력이란 법원에 출석하여 유효하게 구술로 변론을 할 수 있는 능력을 말한다. 소송능력이 소송 전반에 걸친 자격이라면, 변론능력은 기일에서의 실제 수행 능력을 의미한다.

2. 변론무능력자

- 당사자가 소송능력자라 하더라도 말을 할 수 없거나 정신적 장애 등으로 인해 재판장의 질문에 적절히 응답할 수 없는 경우 법원은 변론을 금지할 수 있다. 또한 변호사 대리 원칙이 적용되는 소송에서 변호사를 선임하지 않은 경우에도 실질적 변론능력이 없는 것으로 취급될 수 있다.

3. 변론능력흠결의 효과

(1) 소송행위의 유효요건

- 변론능력이 없는 자가 행한 구술 진술은 법률상 효과를 발생시키지 못한다.

(2) 변호사선임명령 불응 시 소·상소의 각하

- 법원이 변론능력 부족을 이유로 변호사 선임을 명하였음에도 이에 응하지 않을 경우, 법원은 판결로서 소나 상소를 각하할 수 있다.

(3) 변론능력 흠결을 간과한 판결의 효력

- 변론능력은 소송의 원활한 진행을 위한 기술적 능력이므로, 이를 간과하고 판결이 내려졌더라도 판결 자체가 당면무효가 되지는 않는다.

V. 결론

- 당사자의 자격은 소송의 주체가 갖추어야 할 기본적 요건으로서, 당사자능력부터 변론능력에 이르기까지 단계별로 엄격한 판단이 요구된다. 당사자 능력이 소송의 문턱을 넘기 위한 최소한의 자격이라면, 당사자적격은 구체적인 권리 실현의 정당성을 부여하며, 소송능력과 변론능력은 절차의 적법한 수행을 보장한다. 법원은 이러한 자격 요건을 직권으로 조사함으로써 부적격한 당사자에 의한 소송 남발을 방지하고, 동시에 보정 제도를 통해 진정한

권리자가 절차에서 배제되지 않도록 균형 있는 사법 행정을 펼쳐야 한다. 특히, 복잡해지는 현대 사회의 분쟁 구조 속에서 제3자 소송담당이나 비법인 단체의 소송수행권에 대한 명확한 해석은 사법 정의 실현의 핵심적 과제라 할 것이다.